



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

1.	נציגות הבית המשותף ברח' היבנר 39 פתח תקוה באמצעות מר יעקובוביץ אריה ומר הברמן חיים	תובעים: (נתבעים שכנגד בהליך 451/20)
2.	לוי משה	
3.	לוי ליאורה מרים	
4.	יעקובוביץ אריה יוסף	
5.	יעקובוביץ צפורה	
6.	לבני אליהו	
7.	לבני שושנה	
8.	ויצמן ליאון	
9.	ויצמן מזל	
10.	הברמן חיים	
11.	ליכטנשטאל אפרת	
12.	שריד צפורה	

כולם באמצעות ב"כ: עו"ד מיכלס גיל ואח'

נגד

1.	מימון יוסף	נתבעים:
2.	מימון נטלי	(תובעים שכנגד בהליך 451/20)

באמצעות ב"כ: עו"ד קניאל מרדכי ואח'

פסק דין

לפניי סכסוך, המציב זה מול זה את נציגות ודיירי הבית המשותף ברחוב היבנר 39 בפתח תקווה, אל מול בעלי דירת הפנטהאוז. פסק דין זה יבחן את גבולות הרכוש המשותף, בעיקר ביחס לגג הבית המשותף.

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב היבנר 39 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים והמוכר כחלקה 295 בגוש 6712 (להלן – "הבית המשותף"). על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית חל תקנון מוסכם אשר נרשם עם מתן צו רישום הבית המשותף ביום 24.6.1986 (להלן – "התקנון המוסכם").

2. התובעים בתביעה הראשית (הליך 198/20 להלן – "התביעה הראשית") הם הנתבעים בתביעה שכנגד (הליך 451/20 להלן – "התביעה שכנגד"), נציגות הבית המשותף (להלן – "הנציגות") ובעלי דירות בבית המשותף (להלן – "התובעים").

3. הנתבעים בתביעה הראשית, הם יוסף ונטלי מימון, הם גם התובעים שכנגד בתביעה שכנגד, והם הבעלים של דירת הפנטהאוז המצויה בקומה החמישית בבית המשותף, והרשומה כתת חלקה 9 (להלן – "הנתבעים").

4. בקצרה אציין שבתביעה הראשית, התבקשו הסעדים הבאים: סילוק יד הנתבעים, במסגרתו על הנתבעים להרוס תוספות בניה שנטען שבנו על גג הבית המשותף בלי שניתנה הסכמת התובעים כנדרש בדין ובניגוד להיתר, וכן להורות על השבת המצב לקדמותו גם ביחס לדוד השמש; מתן צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם משטחי הרכוש המשותף ובכלל זה שטח גג חדר המעליות; סילוק הצנרת ומערכות שהתקינו הנתבעים על גג חדר המעליות, ופתיחת חלונות האוורור ופתח היציאה מחדר המעליות לגג; וכן התבקשו תשלומי איזון בגין ניצול זכויות בניה שבבעלות התובעים. יוער, כי הסעד הכספי שאליו עתרו התובעים שעניינו פיצויים בגין נזקים שנגרמו להם בשל עבודות הבנייה נמחק על ידי כב' המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין, אושרת ארפי מוראי, בהחלטתה מתאריך 8.12.2020 (198/20 מימון יוסף נ' נציגות הבית המשותף ברחוב היבנר 39 פתח תקווה (נבו 08.12.2020)). על החלטה זו הוגש על ידי הנתבעים ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז (הליך 37491-01-21), ובתאריך 13.4.2021, ניתן פסק דין בהסכמת הצדדים ולפיו הסעד הכספי שעניינו שווי זכויות הבנייה שניצלו הנתבעים, יימחק מכתב התביעה תוך שמירת טענות התובעים בערכאה המוסמכת. יתר חלקי הערעור נדחו.

5. במסגרת התביעה שכנגד, התבקשו מגוון סעדים אשר כללו דרישות להריסה, סילוק, והתאמת הבנייה להיתר. בנוסף, דרשו הנתבעים סילוק דוד שמש, שלטענתם הותקן שלא כדין ברכוש הפרטי, וכן דמי שימוש ראויים בגינו. עוד נתבקש צו מניעה, האוסר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על התובעים להיכנס לשטח דירת הנתבעים. הסעדים הכספיים שנתבעו הועמדו על סך כולל של 1,248,301 ש"ח, והם נגעו לפיצויים נזיקיים שונים, ובכללם פיצוי בגין הפרת פרטיות, עוגמת נפש ותביעת לשון הרע. בהחלטתי מתאריך 4.4.2021, ניתנה הוראה למחוק את הסעדים הכספיים המפורטים בכתב התביעה שכנגד (סעיפים 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 84, 86, 87.7, 87.8, ו- 87.10), למעט סעדים כספיים שעניינם דמי שימוש עבור דוד השמש, אשר עילתם הסגת גבול, וכן סעד שעניינו החזר הוצאות בסך 19,188 ש"ח בגין איטום חדר המעלית.

מהלך הדיון בקצרה

6. במסגרת ההליכים שבכותרת, התקיימו שלושה דיוני הוכחות, שבהם נחקרו עדי הצדדים. מטעם התובעים העידו: המומחה מר דוד בריל (להלן-"**שמאי התובעים**"), נציג העירייה מר ירון הלפגוט, התובע 10 מר חיים הברמן, והתובע 4 מר אריה יעקבוביץ'. מטעם הנתבעים העידו העדים הבאים: המומחית גב' מיכל ראבד (להלן-"**אדריכלית הנתבעים**"), הנתבע 1 מר יוסי מיימון וגב' רחל שועלי, הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים (להלן-"**פרוטוקול הדיון**").

7. בנוסף, ערכתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם המלומדים, כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענותיהם (להלן-"**הביקור במקום**"). ניסיונות רבים להביא את הצדדים להסכמות, לא צלחו. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם הן ביחס לתביעה הראשית והן ביחס לתביעה שכנגד

8. לפי תשריט הבית המשותף, לדירת הנתבעים הוצמד רק השטח המסומן באות י"א אשר שימש כתקרת דירת הנתבעים בשטח של 96.62 מ"ר. כל יתר שטחי הגג מהווים חלקי הרכוש המשותף. לפיכך כל שינוי או בניה שנעשתה בשטחים אלו ללא היתר קנייני ותכנוני מהווה השתלטות על הרכוש המשותף ויש להורות על הריסת הבנייה והשבת המצב לקדמותו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בשנת 1988 הוציאה העירייה היתר בניה למשפחת שועלי, הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים לסגירת מרפסת על הגג בשטח 26 מ"ר. הנתבעים אשר רכשו את הדירה ממשפחת שועלי בשנת 2018 פנו לדיירי הבניין בבקשה לקבל את הסכמתם להרחבת דירתם עד הקירות החיצוניים של הבניין. באסיפת דיירים שהתקיימה ביום 11.2.2019 החליטו התובעים להתנגד לבקשת הנתבעים. אולם הנתבעים פנו בכל זאת לעירייה לקבלת היתר בניה שכלל בין היתר שינוי של חזית הבניין וניוד זכויות בניה של התובעים. הנתבעים חרגו מהיתרי הבנייה שהוצאו להם, חרף ביקורות חוזרות ונשנות מטעם העירייה, שבגינן הוצאו להם צווי הפסקת עבודה.
10. עוד בטרם תחילת עבודות הבנייה, הנתבעים או מי מטעמם חסמו את פתח היציאה מחדר המעלית לגג שהיה במקומו מאז נבנה הבית. הנתבעים ניתקו צלחת לווין של חברת יס, והזיזו את דוד השמש של התובעים 6-7 (להלן - "משפחת לבני"), בניגוד להוראת כב' המפקחת בהחלטה מתאריך 8.12.2020. כמו כן הנתבעים יצקו גג חדש בין הקיר הדרומי לבין חדר המעלית.
11. כן נטען שהנתבעים הזיזו ארון תקשורת מחדר המעלית, ניתקו גלאי עשן וריתכו את הדלת למשקוף. עקב הסכנה ובהוראת כב' המפקחת מתאריך 4.12.19, הזמינו התובעים איש מקצוע שיפתח מחדש את פתח היציאה, אולם חרף זאת, הנתבעים שבו ואטמו אותו. לטענת התובעים, הנתבעים חסמו ואטמו את חלונות חדר המעליות שפנו לכיוון הגג הדרומי, ובכך ביטלו פתחי שחרור עשן והפכו את חדר המדרגות למלכודת אש.
12. עוד נטען שהנתבעים אטמו את פתח היציאה מחדר המעלית לגג העליון, מנעו מהתובעים גישה לגג חדר המעלית והשתלטו על כל שטחי הגגות המשותפים. התובעים טוענים כי דלת היציאה לחדר המעלית הייתה קיימת מאז בניית הבניין ושימשה לגישה במשך 40 שנה. נטען גם כי הנתבעים מונעים שלא כדין את היציאה לגג המשותף ומונעים שימוש בגג חדר המעלית ובכל יתר חלקי הגג המשותף.
13. לפיכך מבוקש להורות על הריסת הקיר הדרומי והגג שיצקו הנתבעים בינו לבין חדר המעלית. וכן להורות על השבת המצב לקדמותו וסילוק ידם של המשיבים מהרכוש המשותף. בכלל זה פתיחה מחודשת של פתח היציאה מחדר המעלית,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השבת כולא הברקים למקומו, וסילוק דוד השמש מערכות מיזוג אוויר וכל דבר אחר שהתקינו הנתבעים בשטח הרכוש המשותף.

14. **טענות התובעים בתביעה שכנגד:** התובעים חוזרים על טענתם כי מדובר בתביעת השתקה. בניגוד לטענת הנתבעים, התובעים הזכירו עוד בכתב ההגנה של התביעה שכנגד כי היו מוכנים לתיקון צו רישום הבית המשותף ורישום הבניה בשטח י' בתשריט חלק מדירת התובעים. כמו כן, בהיתר הבניה מופיע היתר להגדלת שטח דירתם ב- 97.1 מ"ר ולא ב- 96 מ"ר כפי שפורט בכתב התביעה.

15. כן נטען שהתובעים הזכירו עוד בכתב ההגנה את טענת ההתיישנות ביחס לדוד השמש, סככת החניה, וחריגות בניה שביצעו לכאורה. טענת ההתיישנות קמה מכוח ס' 204 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן-"**חוק התכנון והבניה**").

16. ביחס לטענת הנתבעים על הרחבות בנייה ושינוי החזית הצפונית, יש לקבל את עדותם של התובעים חיים הברמן ואריה יעקובוביץ המתגוררים בבניין מזה 40 שנים, ואשר העידו שחזית הבניין הצפונית נותרה כשהייתה בעת שנבנה הבניין. מיכל ראבד, אדריכלית הנתבעים, הודתה בחקירתה כי היא לא מודדת מוסמכת, וכי עדותה ניתנה על סמך מראה עיניים בלבד.

17. ביחס לפרטי התביעה, סככת החניה של משפחת לבני נבנתה בהסכמת רוב בעלי הדירות, והיא איננה מפריעה לאיש מלבד משפחת לבני עצמם. לולאת הקשירה איננה מצריכה היתר בניה, וכן הוונטות הותקנו על ידי הקבלן ואינן מצריכות היתר גם הן. כך או כך, התביעה התיישנה. בין היתר הוכח כי השימוש בחדרי המדרגות נעשה בהסכמה.

18. הוכח כי דוד השמש של משפחת לבני הוצב על שטחי הרכוש המשותף, ולבני מעולם לא הסכימו לשלם בגין הצבת הדוד. כמו כן נוכח התעמרות הנתבעים במשפחת לבני וההרס שנגרם לדוד, אין מקום לפסוק תשלום שכזה ממילא.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדוד הותקן בשעתו בהסכמת הדיירים כולל משפחת שועלי, הנתבע הודה בחירתו כי ידע על מיקום הדוד בעת שרכש את הדירה.

19. הנתבעים לא הוכיחו כי היה צורך להחליף את מיכלי המים, ולפיכך אין מקום לחייב את התובעים בגינם. לפיכך, מתבקש המפקח להורות על קבלת התביעה העיקרית וליתן לתובעים את מלוא הסעדים המבוקשים, וכן להורות על דחיית התביעה שכנגד. בנוסף, מתבקש לחייב את הנתבעים בהוצאות המשפט, לרבות שכר טרחת עורך-דין.

תמצית טענות הנתבעים בסיכומיהם הן ביחס לתביעה הראשית והן ביחס לתביעה שכנגד

20. לטענת הנתבעים, יש לדחות את התביעה הראשית ולקבל את התביעה שכנגד. נטען שרוב הסעדים שאליהם עתרו התובעים נדחו על הסף בערכאה זו, ובערכאת הערעור. בכלל זה הסעד הכספי של התובעים נדחה, וכן סעד ההריסה צומצם רק לבניה שחורגת לכאורה לתחומי הרכוש המשותף.

21. אשר לטענות התובעים הנוגעות לחריגה מהיתרי הבנייה - אין מקומן של טענות אלו בהליך זה שכן סמכות המפקח איננה נוגעת להליכים תכנוניים, אלא להליכים קנייניים בלבד.

22. התובעים נמנעו מלהביא ראיות אשר יכלו לשמש לטובתם, ולפיכך יש להניח על פי כללי הדין כי לו היו מובאות ראיות אלו, היו הללו פועלות לרעתם. בכלל זה יצוין כי התובעים לא הגישו חו"ד של מודד מוסמך אלא של שמאי, ונמנעו מלהעיד את יתר הדיירים בבניין.

23. מפת המדידה אשר הציגו התובעים איננה קבילה שעה שלא הוגשה לגביה חו"ד מומחה, בהתאם לפסיקת בית המשפט השלום בב"ש ת"א 13533-09-12 מנהל מקרקעי ישראל – מחוז דרום נ' שללי ואח' (נבו 19.1.14).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. צו הפסקת הבנייה שהוצא לנתבעים התייחס רק לשתי עבודות ספציפיות, המדרגות והקיר הדרומי/המעקה, ואכן הצו קוים. כמו כן התובעים הודו בעצמם שנאלצו לעלות לגג כדי להבחין בתוספת הבנייה במעקה. עדות זו מוכיחה כי מדובר בתביעה קנטרנית.

25. כן נטען שבהיעדר עדות מצד אשת מר לבני (התובעת 7), ומשנחק תצהירו, אין בנמצא עדות קבילה הסותרת את גרסת הנתבעים וגרסת גב' שועלי, בכל הנוגע להתנהלותם אל מול בני הזוג לבני ולגורלו של דוד השמש. למעלה מן הצורך, התובעים עצמם אישרו כי דוד השמש הוצב בהסכמת הדיירים הקודמים, ובקשה זו, לשיטתם, מלמדת כי התובעים לא ראו בשטח האמור כרכושם. עוד נטען על ידי הנתבעים כי הנסיבה שבני הזוג לבני ביקשו את הסכמת משפחת שועלי להצבת דוד שמש מחוץ לגג דירה 11, מתוך תפיסה כי נדרשת הסכמה כאמור, מהווה אינדיקציה לכך שהגג אינו בגדר רכוש משותף. זאת ועוד, התובעים עצמם מאשרים כי כל כניסה לגג בעבר נעשתה בתיאום עם משפחת שועלי. בנוסף, טוענים הנתבעים כי מר יעקובוביץ אישר בחקירתו כי אין לו ידיעה אישית באשר לטענות הנוגעות לדוד השמש של בני הזוג לבני, למעט העובדה כי הצבתו נעשתה בהסכמת משפחת שועלי.

26. הוכח שהשימוש במיכלי המים ובאנטנת הטלוויזיה, אשר מוקמו על הגג המשותף, פסק לפני כ-15 שנים, והתובעים והנציגות הסכימו לפינוי המיכלים מהגג. עוד נטען על ידי הנתבעים כי מר הברמן אישר בחקירתו שלא ראה את הנתבעים מנתקים או מסירים את צלחת הלוויין, אלא שמדובר במסקנה או השערה מטעמו.

27. דלת הברזל מהצד הדרומי לא מופיעה בתשריט הבית המשותף וגם לא בהיתרי הבנייה.

28. נטען שהתובעים משתמשים בזכותם הקניינית שלא בתום לב, שעה שאסיפת בעלי הדירות נוטה לאשר את כל בקשות הדיירים מלבד בקשות הנתבעים. התובעים אף עשו דין לעצמם בעת שפתחו את היציאה לגג מחדר המעלית, ולפיכך אין לתת סעד למי שלא בא בניקיון כפיים. הנתבעים גורסים כי התנגדות התובעים לעבודות שביצעו הנתבעים על גג הבניין היא קטנונית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ונובעת מחוסר חיבה אישית, ובין היתר מהרצון להציב פאנלים סולאריים בעתיד, ואינה עולה בקנה אחד עם החובה לעשות שימוש בזכות הקניינית בתום לב.

29. נטען כי הגגות החדשים, אשר נוצרו עקב סגירת מרפסות או הרחבת גג, אינם נכללים בגדר הרכוש המשותף. ההלכה הפסוקה קבעה זה מכבר כי גגות מסוג זה, המהווים המשך ישיר של הגג הקיים, יירשמו כהצמדה לדירה הרלוונטית אליה הם משויכים, ובמקרה זה, לדירת הנתבעים.

30. טענת התובעים, לפיה הגגות שנוצרו כתוצאה מסגירת המרפסות או מהרחבת גג דירה 11 מהווים רכוש משותף, יוצרת אנומליה ברורה, בלתי הגיונית ובלתי מוצדקת, ופוגעת מהותית בנתבעים. יתרה מכך, טענה זו עלולה להוביל למצב בלתי אפשרי של מחלוקות בנוגע לנזילות ולאחריות לאיטום. הנתבעים גורסים כי המרפסות שנסגרו על ידם עומדות בכל התנאים הנדרשים להגדרת "דירה" על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין. לפיכך, מדובר במרפסות המהוות המשך טבעי וחלק בלתי נפרד מגג דירה 11, אשר הוצמד לדירת הנתבעים, ואינן בגדר רכוש משותף. מכאן, שלתובעים אין כל זכות לעשות שימוש במרפסות אלו, לרבות בגג שלהן. הנתבעים סבורים כי ההיגיון מחייב שעה שבעל דירה סוגר מרפסת ונוצר מעליה גג חדש, לא יעלה על הדעת כי בעלי הדירות האחרים יוכלו להציב על גג זה דוד שמש.

31. כמו כן, טוענים הנתבעים שכלל הוא שלכל בעל דירה יש בעלות עד קו האמצע של המחיצה המפרידה בין דירתו לבין הרכוש המשותף. לכן, המחצית הפונה לעבר דירת הנתבעים היא בבעלותם בלבד, ואילו המחצית הפונה לצד השני היא רכוש משותף לפיכך רשאים היו הנתבעים לאטום את דלת הפלדה שהייתה קבועה בקיר על הגג הפונה לדירת הנתבעים. לטענת הנתבעים, דברים אלו יפים גם ביחס לקיר שנפרץ על ידי הנציגות שלא כדין, וגם לקירות המקיפים את חדר המעלית וגובלים בגג יא'. הנתבעים גורסים כי כאשר קיר הוא חיצוני מצד אחד ופנימי מצד שני, הצד הפנימי הוא חלק מהדירה שאליו הוא פונה. הנתבעים טוענים כי העלייה לחדר המעלית הייתה באמצעות סולם, וכי הנתבעים סגרו את החלון בחדר המעלית כדי להקטין נזקים שנגרמו להם עקב הסגרת הגבול של התובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. לפיכך, מתבקשים הסעדים הבאים: תיקון צו בתים משותפים באופן שישקף את שטח דירת הנתבעים בפועל; הריסת חריגות הבניה בדירות התובעים, שאינן תואמות את תכנית ההיתר של הבית המשותף; השבת המצב לקדמותו ביחס לרכוש המשותף כולל הסרת הסככה שהתקינו משפחת לבני; סילוק יד מכלל השטחים ברכוש המשותף; איסור כניסה לדירת הנתבעים, לרבות השטחים המוצמדים לה; והחזר הוצאות בגין תיקונים שהנתבעים נאלצו לבצע בגין מפגעים וליקויים ברכוש המשותף.

33. **טענות הנתבעים בתביעה שכנגד:** יש לקבל את הבקשה לתיקון צו הרישום לבית המשותף ולהתאימו לשטח הדירה בפועל. כמו כן יש לתת צו האוסר על התובעים להיכנס לשטח דירת הנתבעים. הנתבעים גורסים כי טענת ההתיישנות שהעלו התובעים אינה יכולה לעמוד להם, שכן לא נטענה בהזדמנות הראשונה והועלתה באיחור ניכר.

34. חריגות הבנייה של התובעים הוכחו בחוות הדעת של המומחית מיכל ראבד, ובהעדר חו"ד נגדית. וכן על ידי עדות התובע יעקובוביץ ונציג העירייה מר הלפגוט מנהל אגף הפיקוח על הבנייה, שהעיד כי קיימת בעיה של שינויים בחזיתות בדירות בבניין שאינן של הנתבעים או משפחת שועלי, וכי נפתח תיק חקירה בעניין.

35. מר הלפגוט אישר בעדותו כי הוונטה והקמת הסככה בחניה דורשים היתר, ולפיכך יש להורות על הריסתם. לטענת הנתבעים, מר יעקובוביץ התחמק משאלות לגבי סגירת התריס בדירתו, והודה שלא היה מודע לצורך בהיתר. לטענת הנתבעים, מר הברמן הודה בחקירתו כי בוצעו שינויים בחלונות בדירות 7 ו-8 של הבניין.

36. הנתבעים טוענים כי חוות דעת המומחית מטעם הנתבעים, גב' מיכל ראבד, והתמונות המופיעות בסעיף 9-13 לתצהירה, מראות בבירור את השוני בין הדירות הנ"ל ליתר הדירות בבניין, ואת הצורך בהיתר לסככה שהתקינו לבני בחנייתם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. הנתבעים מבקשים כי ייפסקו לטובתם דמי שימוש בגין הצבת הדוד על דרך האומדנה וכן החזר הוצאות בגין פינוי מיכלי המים והצנרת שהנתבעים נאלצו לבצע במקום הנציגות.

**דיון והכרעה
התביעה הראשית**

38. אופן הילוכי בפסק דין זה יהא כדלהלן: ראשית, אציג סקירה נורמטיבית, הן ביחס לסמכות המפקח לדון בנושאים טכנוניים, הן ביחס לסמכות המפקח לדון בסילוק יד, והן ביחס להבנה מהו רכוש משותף. סקירה זו תסייע בהבנת הטיעונים ובהתוויית גבולות הדיון, ובכך תמקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים ותצמצם את היריעה. לאחר מכן, אדון בטיעונים לגופם של דברים.

39. הצדדים הרבו לטעון ולמקד את טענותיהם ביחס להיתרי הבנייה השונים שניתנו לדירות הצדדים בבית המשותף. אלא, כפי שכתבתי לא פעם [(ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.3.2022) (להלן: "עניין נחמיאס"), ישנה הפרדה בין ההליך התכנוני לבין ההליך הקנייני. לפיכך נפסק כי ככלל, סמכות מוסדות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות, ואין הם מוסמכים לדון בשאלות קנייניות (ע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011); בג"ץ 1578/90 הלן איזון נ' הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990)]. המפקח על רישום מקרקעין, אינו דן בנושאים טכנוניים, אלא בנושאים קנייניים בהתאם לסמכותו לפי חוק המקרקעין. לפיכך, אין הוא צריך להידרש לטענות הקשורות להיבטים תכנוניים. בירור טענות אלו מצוי בסמכות מוסדות התכנון.

40. ער אני לכך שלעיתים, נדרש המפקח לבחון גם נושאים טכנוניים, ולו כדי לבדוק האם בידי הצד הרלוונטי להליך קיים היתר כדין מטעם הרשות התכנונית. לדוגמה, בהליכים לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008, נדרש המפקח לבחון האם בידי הצד המבקש את ביצוע עבודות החיזוק קיים היתר בנייה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החיזוק. כך גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במסגרת סימן ג'1 לחוק המקרקעין, העוסק בשינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה, כאשר מתבררת טענה כי בעל דירה ביצע שינויים ברכוש המשותף שעניינם "הרחבת דירה", על המפקח לבחון, בין היתר, האם אותה "הרחבה" היא כזו "שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף" (ראו הגדרת המושג "הרחבה" בסעיף 71א לחוק המקרקעין). אולם, כאמור, בענייננו, הטענות התכנוניות הרבות שהעלו הצדדים זה נגד זה, אינן טענות שבסמכותי לדון בהן. מובן ששמורות לצדדים מלוא טענותיהם התכנוניות בפני הערכאה המתאימה לכך, אלא שפסק דיני יתמקד, בפן הקנייני.

41. אשר לפן הקנייני, חשוב להדגיש כי המחלוקת שעניינן סילוק היד שבמחלוקת, דורשות דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים, ובעיקר עד לאן מתפרשת בעלותם. אולם בכל הקשור לבעלות ולנובע ממנה, אדון אגב גרר בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בשטח שבמחלוקת [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)] והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

42. כמו כן, עוד חשוב להדגיש, שבהתאם להלכה הפסוקה, על המפקח על רישום מקרקעין (להלן-"המפקח") לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. הצדדים הפליגו בטענותיהם ביחס לחוות דעת שונות ומסמכים נוספים שהוגשו על ידם, אך כאמור, אבחן כיצד טענות הצדדים מקבלות ביטוי במסמכי הרישום של הבית המשותף. כידוע, מסמכי הבית המשותף, מהווים הוכחה חותכת לתוכנם, שכן תכלית הרישום הוא ליצור אמון הציבור במרשם ובאפשרות להסתמך עליו כמרשם סופי, בלעדי ומוחלט. [סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין"); ע"א 1559/99 שושנה צימבלר נ' רבקה תורג'מן נז(5) 49 (2003)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. חלקי הרכוש המשותף הוגדרו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, כדלהלן: **"רכוש משותף - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת"**. כך שהגדרתו של הרכוש המשותף היא הגדרה שיווית. כל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים הרשומים כדירות [ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור, בפסקה 33 (נבו) 27.08.2009].

44. ככל שמדובר ברכוש משותף, בעל דירה רשאי לעשות כל שימוש ברכוש המשותף, ובתנאי שמדובר בשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, שאינו מונע שימוש דומה מאחרים, זולת אם נקבעה בתקנון המוסכם הוראה מפורשת בקשר לכך או אם התקבלה החלטה של האסיפה הכללית בבית המשותף בדבר טיב ואופן השימוש המותר ברכוש המשותף בהתאם לאמור בסעיף 5(א) לתקנון המצוי [ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה, פ"ד לו(4) 737, 740-741 (1983); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974)].

45. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 16 (נבו) 25.01.2022].

46. כמו כן, על פי ההלכה הפסוקה, ככלל, כאשר מוקם מבנה נוסף ונוצר גג חדש, גג חדש זה הופך באופן אוטומטי לרכוש משותף של כלל בעלי הדירות. זכויותיהם של יתר בעלי הדירות בגג החדש מתגבשות עם השלמת המבנה, וזאת כל עוד לא הוסכם אחרת במפורש על ידי כל בעלי הדירות או בתקנון המוסכם [ביחס להוראה בתקנון ראו למשל ע"א 3095/20 אמיר הלפרין נ' אורה כהנא (נבו) 15.12.2021]. הרציונל העומד בבסיס קביעה זו הוא כי כל גריעה מהרכוש המשותף, בין אם בדרך של הצמדה ובין אם בדרך אחרת, חייבת להיות מפורשת, ברורה וחד-משמעית. אין להסיק על הצמדת גג חדש מכללא, או בדרך של היקש מהסכמה כללית לבנייה עצמה. זאת משום שגריעה שכזו אינה עניין טכני גרידא, אלא פוגעת באופן ישיר ומהותי בזכויות הקנייניות של כלל הדיירים בבית המשותף, ומצמצמת את חלקם בנכס המשותף. [ע"א 239/79 ישראל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גלבורט נ' הממונה על המרשם, לד(2) 807 (1980) (להלן-"הלכת גלבורט"); ת"א (מחוזי ת"א) 1539/06 שלמה ניצן מינץ נ' צבי גבאי (נבו 20.11.2011); ע"א 2427/11 מפעל חסד תורה ירושלים, ת"ו נ' ננסי פליישמן (נבו 11.3.2014) ה"פ (מחוזי ת"א) 21919-09-12 קרשין יהודה נ' זילברמן יעקב (נבו 18.11.2014).

47. עוד יש להדגיש, כי ככלל, קיר חיצוני הוא רכוש משותף. הפסיקה הדגישה שקיר חיצוני הוא רכוש משותף, גם אם הוא פונה למרפסת פרטית [ע"א 381/66 חיים לוי, ו-9 אח' נ' מרים לינקביץ, כ(4) 557 (להלן-"פסק דין חיים לוי"); ע"א 429/80 צבי גרפינקל נ' דיאנה ארליך, לז(4) 141 (1983); ע"א (מחוזי ירושלים) 2499/01 בן ברוך אביטל נ' קשפיצקי אסתר ז"ל, בפסקה 9 (נבו 21.3.2002)]. הטעם לכך נעוץ בכך שקיר חיצוני אינו משרת אך ורק את הדירה הסמוכה לו. הוא מהווה חלק אינטגרלי מהמעטפת החיצונית של הבניין כולו, תומך במבנה, מגן עליו מפגעי מזג האוויר, משמש לבידוד, ומשפיע על חזותו האסתטית של הבית המשותף. לכן, ככלל, קיר חיצוני שומר על מעמדו כרכוש משותף גם אם הוא גובל בשטח פרטי או גובל בשטח שהוצמד לדירה, כגון מרפסת, גזוזטרה, חצר או גינה. הצמדת השטח הסמוך לקיר לא הופכת את הקיר עצמו לרכוש פרטי של בעל הדירה. יתר על כן, העובדה שהגישה לאותו קיר אפשרית, או אף נוחה יותר, רק מדירה מסוימת, אינה משנה את סיווג המשפטי. סיווג הרכוש המשותף לא נקבע על פי נוחות הגישה אליו. מתן אפשרות לבעל דירה לטעון לבעלות פרטית על קיר חיצוני רק משום שהוא גובל בשטחו, עלול להוביל לתוצאות אבסורדיות ולפגיעה קשה באחידות המבנה, ביציבותו ובזכויותיהם של יתר בעלי הדירות. לפיכך, כל שינוי במעמד זה, כלומר, גריעה של קיר חיצוני מכלל הרכוש המשותף והפיכתו לרכוש פרטי, מחייבת הסכמה מפורשת וחד-משמעית של כל בעלי הדירות בבית המשותף, או קביעה מפורשת וברורה בתקנון המוסכם של הבית המשותף.

הגגות החדשים שנוצרו כתוצאה מההרחבה הם רכוש משותף

48. כפי שעולה מתשריט ומתקנון הבית המשותף, לדירת הנתבעים הוצמדו שני גגות המסומנים באותיות י' ו-י"א. שטחים אלו כוללים את כל גגות הבית המשותף למעט



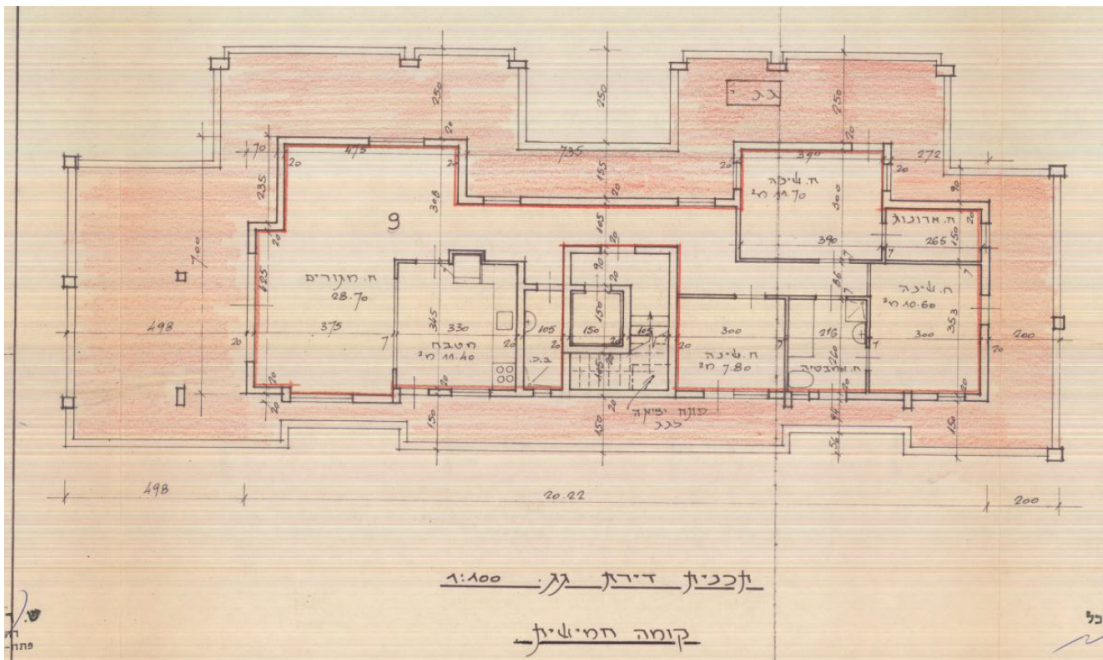
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח חדר המעלית והשטח שבין הקיר הדרומי של חדר המעלית לקיר הדרומי של הבניין.

49. אין מחלוקת בין הצדדים כי בוצעה הרחבה ביחס לדירת הנתבעים. כך נוכחתי גם אני מביקור שביצעתי בבית המשותף יחד עם הצדדים. למען הבהירות אפרט את הרחבות הבנייה שבוצעו בדירת הנתבעים. דירת הנתבעים כאמור, ממוקמת בקומה החמישית של הבית המשותף וכעולה מהתשריט, היא מוקפת במרפסת גג שהוצמדה לדירת הנתבעים, שמסומנת כגג י' בתשריט, כפי שמופיע להלן:



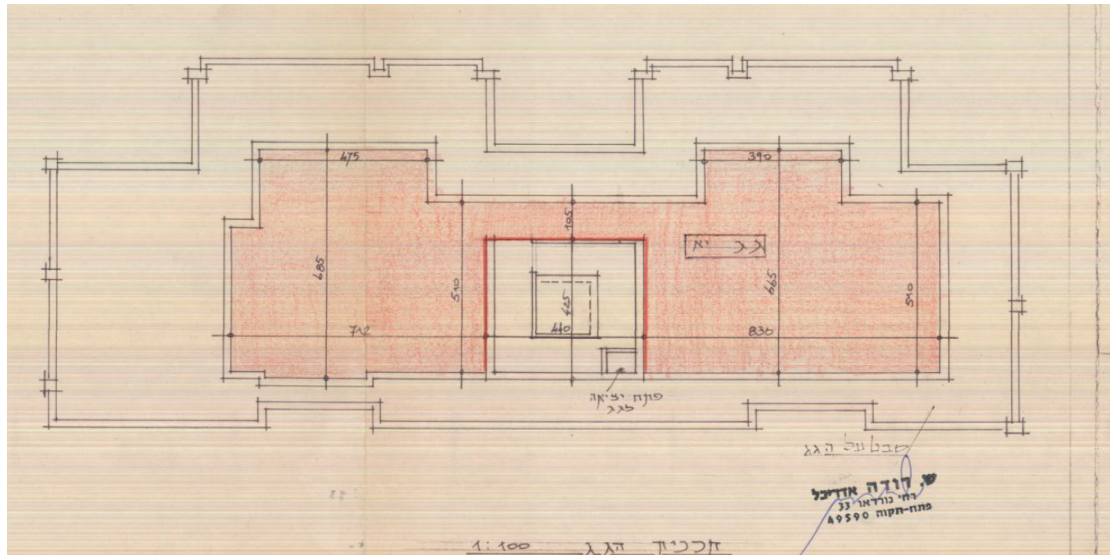
50. בקומת הגג (קומה 6), כפי שהיא מוצגת בתשריט הבית המשותף, מופיעה הצמדה נוספת לדירת הנתבעים, המתוארת "גג י"א" בתשריט. שאר הגג, זה שאינו מסומן כגג י"א, הוא רכוש משותף. וכך קומת הגג מקבלת ביטוי בתשריט הבית המשותף:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



51. בתאריך 11.1.1988, ניתן לבעלי הדירה הקודמים של דירת הנתבעים, משפחת שועלי, היתר בנייה מספר 2910 (להלן-"היתר 1988"), במסגרתו הותרה תוספת בנייה על הגג כפי שנרשמה בהיתר 1988 "תוספת בניה על ידי סגירת פיתחי פרגולה" (ראו סעיף 4 לחוות הדעת של אדריכלית הנתבעים וכן סעיף 8.2 לחוות דעתו של שמאי התובעים).

52. כמו כן, אין מחלוקת בין הצדדים, שבתאריך 24.10.2019 ניתן לדירת הנתבעים היתר בנייה מספר 2019314 (להלן-"היתר 2019") שבמסגרתו הותרה "הרחבת קומה חלקית ע"ח שטחי חדרים על הגג". שטח הבנייה הכולל שהתבקש בבקשה להיתר הוא 36.95 מ"ר (ראו עמ' 20 לחוות דעתו של שמאי התובעים). בסופו של דבר, וכך גם עלה מביקורי במקום, דירת הנתבעים הורחבה, וכתוצאה מהרחבה זו, נוצרו גגות חדשים.

53. איני יכול לקבל את טענתם של הנתבעים, ולפיה הגג שנוצר כתוצאה מפעולות ההרחבה שבוצעו, משויך קניינית לדירתם באופן בלעדי. כפי שהובהר בהרחבה לעיל, ברירת המחדל המשפטית הברורה, המושרשת היטב בהלכה הפסוקה, היא כי גג חדש הנוצר כתוצאה מבנייה נוספת בבית משותף, הופך באופן אוטומטי לרכוש משותף של כלל בעלי הדירות. כלל זה נועד להגן על זכויותיהם הקנייניות של כלל בעלי הדירות. משכך, הנטל להוכיח כי חל סייג לכלל זה, וכי הגג החדש אינו רכוש משותף אלא הוצמד כדין לדירה ספציפית, מוטל במלוא כובד משקלו על כתפיהם של הטוענים זאת, ובמקרה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דן, על הנתבעים. לאחר שבחנתי את טענותיהם ואת הראיות שהוצגו, הגעתי למסקנה כי הנתבעים לא עמדו בנטל כבד זה, ולא עלה בידם להוכיח כי נכרתה הסכמה מפורשת וחד-משמעית, כנדרש, לגריעת הגג החדש מכלל הרכוש המשותף.

54. הנתבעים נאחזו בטענה המשפטית, ולפיה הגג החדש שנוצר כתוצאה מעבודות ההרחבה של ההיתרים השונים, הוא לא רכוש משותף, אלא קניינם הפרטי. אלא שכפי שהסברתי לעיל, איני מקבל טענה זו. בהלכת גלבורט לעיל, נקבע שכלל כאשר מוקם מבנה נוסף על גג שהוצמד לדירה מסוימת ונוצר גג חדש, גג זה הופך לרכוש משותף של כלל בעלי הדירות.

55. הנתבעים ניסו להסתמך בסיכומיהם על פסק דין ע"א (מחוזי ירושלים) 190/84 אליצור דיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין, תשמה (2) 265 (1985) (להלן: "עניין דיבון"), אולם גם בהתעלם מהפער הנורמטיבי בין פסק דין זה לבין הלכת גלבורט לעיל שיצאה מבית המשפט העליון [ראו סעיף 20 (ב) לחוק יסוד: השפיטה], אין הנידון שם דומה לענייננו, וממילא אין סתירה בין ההלכה שנקבעה בעניין גלבורט, לבין הקביעות שנקבעו בעניין דיבון.

56. בפסק הדין בעניין דיבון, שעסק באופן הרישום, נקבע כי פירושו הנכון של סעיף 52 לחוק המקרקעין לא מחייב כי כל המופיע לאחר התיבה "לרבות" מהווה אוטומטית חלק מהרכוש המשותף. אלא קודם יש לבחון האם חלק זה ראוי להירשם כ"דירה", הא ותו לא. בפסק הדין בעניין דיבון נקבע כי מרפסת או גג הצמודים פיזית לדירה יכולים להירשם כחלק בלתי נפרד מה"דירה" עצמה ולא רק כ"הצמדה" לרכוש המשותף, וזאת בתנאי שהם מהווים יחידה שלמה ונפרדת מבחינה פונקציונלית וחזותית. בענייננו, אין חולק כי הגגות החדשים שנוצרו אינם ראויים להירשם כ"דירה" עצמאית, וזאת מאחר שאינם מהווים כיחידה שלמה הן חזותית והן פונקציונלית, כך שפסק דין זה לא יכול להוות אסמכתה לטענת הנתבעים. להשלמת התמונה אציין גם כי בעניין דיבון לא נידונה שאלת רישומו של גג חדש כרכוש משותף, אלא של מרפסת המצויה בקומה העליונה של בית משותף.

57. עוד אוסיף שהתקנון המוסכם שנרשם כאמור בתאריך 24.6.1986, לא קבע כל הוראה ולפיה גג שיווצר כתוצאה מהרחבה, יהיה משויך לדירה שביצעה את ההרחבה. כמו כן, לא הוצג לי על ידי הנתבעים מסמך בכתב בחתימת כל בעלי הדירות, ולפיו הם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

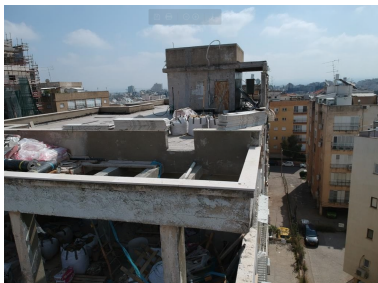
מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

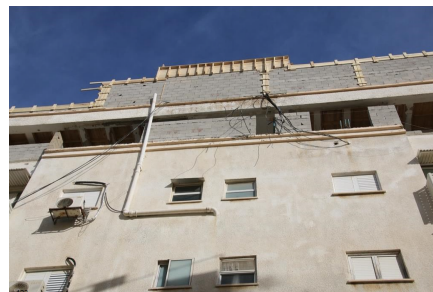
מסכימים באופן מפורש, שגג שייווצר כתוצאה מהרחבה, יוצא מהרכוש המשותף ויוצמד לדירת הנתבעים. כידוע, לא ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף אלא לצורך הצמדתם לדירות [סעיף 62 לחוק המקרקעין; ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אברהם וקמילה אגמי ואח' - דיירי הבית המשותף ברח' קדושי קהיר 36 - 38 בחולון, מד(4) 861 (1990)].

הנתבעים הגביהו את הקיר הדרומי, וקירו את דוד השמש של לבני, בשעה שהן הקיר והן הדוד, ממוקמים ברכוש המשותף

58. עבודת ההרחבה שביצעו הנתבעים בקומת הגג (הקומה השישית), כללה את הגבהת הקיר הדרומי של הבניין, ובניית תקרה בין הקיר הדרומי של הבניין לקיר הדרומי של חדר המעלית. כפי שניתן לראות מהתשריט, הבנייה שביצעו הנתבעים בקומת הגג בוצעה מחוץ לשטח המסומן בצבע אדום ולפיכך מדובר על בנייה בשטחי הרכוש המשותף. להמחשת הדברים ולהשלמת התמונה, ניתן לראות את תמונות הרחבת הבנייה שבוצעה בקומת הגג, המופיעות כמוצג י"ג במוצגי התביעה:



התקרה בין קיר הבניין לקיר חדר המעלית



הקיר הדרומי המוגבה

59. אזכיר כי במקור, הסעדים שאותם ביקשו התובעים היו הריסת הבנייה בקומת הגג, ורישום הגגות החדשים שנוצרו מסגירת המרפסות בקומה החמישית כשטחי הרכוש המשותף. אלא שבדיון, לרבות במסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי, דייקו ומיקדו התובעים את הסעדים, כך שסילוק היד, יהיה ביחס לבנייה שבוצעה ברכוש המשותף, ולא ביחס לבנייה שבוצעה בהצמדה השייכת לנתבעים (ראו גם הצהרת התובעים בדיון שהתקיים בבית המשפט המחוזי במסגרת הליך 37491-01-21, עמ' 2 ש' (10-9).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

60. איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה אין להסתמך על מפת המדידה של המודד לייפמן לאוניד, שהובאה בעמודים 27-28 לחוות דעתו של שמאי התובעים. לטענת הנתבעים, שמאי התובעים אינו מודד אלא שמאי בלבד, ומשכך יש לפסול כאמור את מפות המדידה שצורפו לחוות דעתו, ולכן טוענים הנתבעים שלא הוכחה על ידי התובעים חריגה לתחומי הרכוש המשותף. להלן טעמי. ראשית, נטל ההוכחה חל על כתפי הנתבעים, שכן הם אלו שטוענים שבנו על גבי חלק המשוויך לדירתם ולא לרכוש המשותף. שנית, וחשוב מכך, ההלכה הפסוקה, מתוך הבנה מעמיקה של מורכבות עבודת המומחים בתחומים שונים, קובעת מפורשות כי מומחה רשאי להיעזר באחרים, בין אם מדובר בעובדים, עמיתים למקצוע, או מומחים בתחומי משנה ספציפיים, לצורך איסוף נתונים, ביצוע בדיקות, או עריכת מדידות, המהווים את התשתית העובדתית לחוות דעתו. עבודת המודד לייפמן לאוניד, במקרה זה, אינה אלא איסוף נתונים מקצועי וטכני, אשר שימש את שמאי התובעים כבסיס עובדתי עליו ביסס את הערכותיו ומסקנותיו המקצועיות. השמאי, בתור מומחה בתחומו, אחראי על ניתוח הנתונים וגיבוש חוות הדעת הכוללת, אך אין כל פסול בכך שיעזר בבעלי מקצוע אחרים לצורך השגת הנתונים הגולמיים [ראו למשל ע"פ 566/89 מאיר מרציאנו נ' מדינת ישראל, מו(4) 539 (1992), בפסקה 6; ה"פ (מחוזי תל אביב-יפו) 554/05 מרדכי זרגרי נ' א.דיגמי יבוא ושיווק בע"מ, בפסקה 25 (נבו 12.1.2006)]. לעניין זה יפים גם הדברים שהובאו בספרו של יניב ואקי "דיני ראיות" כרך ב 845: "במקרים רבים, עבודתו של המומחה וחוות דעתו נעשות בסיועם של גורמים אחרים, כמו עובדים הכפופים לו, ומסקנותיו מתבססות על ממצאים עובדתיים שקבע אדם אחר. ... שאלת קבילותן של עדויות מומחים הנסמכות על עדויות מפי עובדים זוטרים הכפופים להם הוכרעה בעניין מרציאנו, המהווה הלכה לעניין זה. נקבע כי העובדה שהמומחה נעזר בבדיקות שערכו אחרים אינה הופכת את חוות דעתו לעדות מפי השמועה ואין בכך כדי לפגוע בקבילותה". שלישית, בחנתי בעיון רב את חוות דעתה של אדריכלית הנתבעים, אשר הוגשה מטעמם. לאחר בחינה מדוקדקת של חוות דעת זו, לא מצאתי בה כל התייחסות, ובטח שלא חולקת, על ממצאי המדידה שהוצגו על ידי המודד לייפמן לאוניד. היעדר התייחסות זו, ובפרט היעדר מחלוקת מקצועית מצד מומחית שהובאה על ידי הנתבעים עצמם, מחזק את מהימנותן של המדידות שהוצגו. אילו היה קיים אי-דיוק או פגם מהותי במפות המדידה, ניתן היה לצפות כי מומחית הנתבעים תצביע על כך. העובדה שלא עשתה כן, מהווה אינדיקציה נוספת לכך שהמדידות



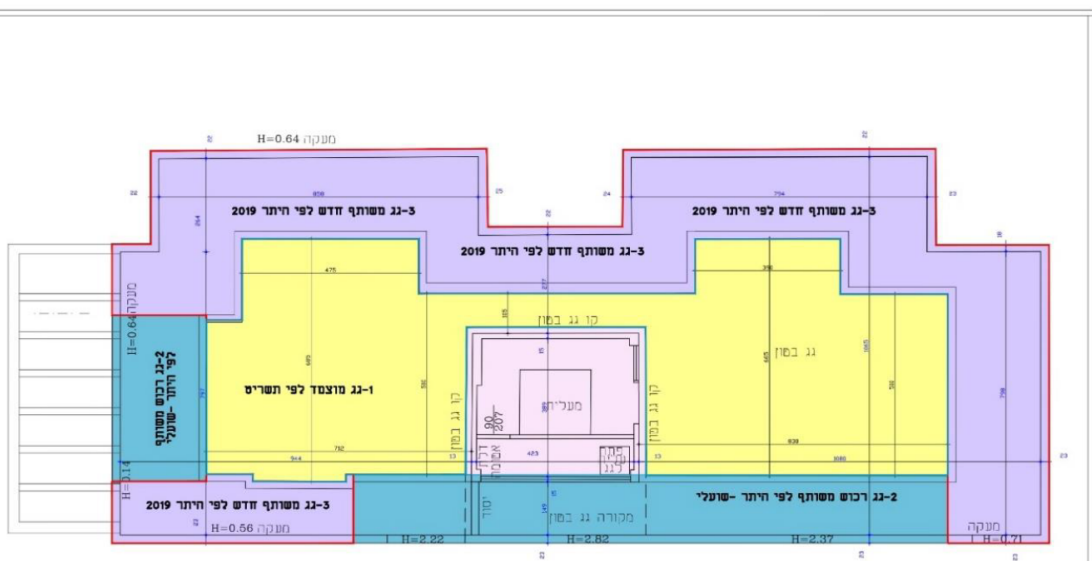
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משקפות נאמנה את המצב בשטח. רביעית, דבר לא מנע מהנתבעים לבקש לחקור את המודד מר לאוניד לייפמן, אך הם ביכרו שלא לעשות כן.

61. לחוות דעתו של שמאי התובעים, צורף כאמור תשריט שהתבסס על המדידה של המודד מר לייפמן (עמ' 28 לחוות דעת שמאי הנתבעים):



62. כעולה מתשריט זה, השטח הצהוב הוא השטח שבמקור הוצמד לדירת הנתבעים בהתאם לתשריט הבית המשותף, אולם שאר הגגות, הם אלו שנוצרו כתוצאה מהרחבות הבנייה בדירת הנתבעים.

63. עברתי בעיון על טענות הנתבעים ביחס לחוות דעתו של מומחה התובעים, לרבות ביחס לטענותיהם בדבר גובה המעקה, גובה הקיר הדרומי, אל מול היתר הבנייה. אולם כפי שצינתי קודם, אין בכוונתי להידרש לדקדוקי היתרי הבנייה התכנוניים, ושמורות לצדדים טענותיהם בפני הערכאה התכנונית. אך מעל הכל אין צורך לענייננו בחוות דעת של מומחה כדי לאשר כי יש פלישה של בנייה אל תוך תחומי הרכוש המשותף.

64. פלישה זו לרכוש המשותף עולה באופן ברור מתשריט הבית המשותף. כפי שעולה מהתשריט, שטח חדר המעלית והיציאה ממנו לכיוון הקיר הדרומי של הבית המשותף, כולל החלק בקיר הדרומי המקביל לחדר המעלית הם חלק מהרכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים לא הכחישו כי הגביהו קיר זה ולפיכך עולה כי אף לשיטתם ביצעו בניה אשר חלקה הוא על תחומי הרכוש המשותף. כמו כן נראה בבירור כי התקרה שיצקו הנתבעים בין הקיר הדרומי לבין חדר המעלית, נמצאת בדיוק בשטח המסומן כרכוש משותף בתשריט. כך שאין צורך במפת המדידה, כדי להיווכח שהנתבעים פלשו לרכוש המשותף, ואין כל משמעות להיתר הבנייה התכנוני, לרבות לא לעניין גובהו של הקיר או גובהו של המעקה.

65. לפיכך עולה כי בהעדר הסכמה מפורשת, לא היו רשאים הנתבעים לבצע את הבנייה שביצעו, ועל כן אני מורה על הריסת הבנייה שביצעו הנתבעים בקומת הגג (הקומה השישית) ברכוש המשותף.

66. **אשר לדוד השמש של משפחת לבני** - בחוות הדעת של שמאי התובעים (סעיף 11.9 לחוות הדעת), חיווה המומחה דעתו ביחס למיקום דוד השמש של משפחת לבני, והגיע למסקנה שדוד השמש האמור, הוצב בשטח הרכוש המשותף, וזאת בהתבסס של תשריט הבית המשותף. מסקנתו של מומחה התובעים, מקובלת עלי. תשריט הבית המשותף מעלה כי החלק שבין הקיר הדרומי, ועד לפיר המעלית, הוא רכוש משותף, ולא הגג שהוצמד לדירת הנתבעים. כך שדוד השמש של משפחת לבני שהוצב בין חדר המעלית לבין הקיר הדרומי, היה למעשה במקור, בשטח שהוא רכוש משותף. לשם המחשה ויזואלית להלן תמונת הקירווי (עמ' 36 לחוות דעת שמאי התובעים) שבנו הנתבעים בשטח הרכוש המשותף, מעל דוד השמש של משפחת לבני וכן חלק מהקיר הדרומי שבמחלוקת:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה מכיוון שחלק מהקיר הדרומי ממוקם בשטח הצמדת דירתם, הוא בהכרח קיר שאינו רכוש משותף. ראשית, כעולה מתשריט הבית המשותף, הקיר הדרומי לא מוצמד לדירת הנתבעים. שנית, בפסק דין **חיים לוי** לעיל, נפסק כי **"יהא אשר יהא דין הגזוזטרה עצמה, הקיר החיצוני של דירת המשיבה, לרבות אותו חלק הימנו הפונה עכשיו לגזוזטרה, הוא בוודאי חלק מן הרכוש המשותף"**. כפי שהסברתי, הרציונל העומד מאחורי הלכה זו הוא תפיסת הקיר החיצוני כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממעטפת הבניין כולו, אשר משרת את כלל הדיירים, תורם ליציבותו המבנית, לשלמותו האדריכלית ולחזותו האחידה. אין כל היגיון משפטי או תכליתי להפריט חלק מקיר חיצוני רק משום סמיכותו לשטח פרטי או מוצמד. קיר חיצוני אינו "שייך" לדירה הסמוכה לו, אלא לבית המשותף כולו. פגיעה בו או שינוי בו משפיעים על כלל הדיירים ועל שלמות הנכס המשותף. על כן, כל עוד לא הוכח אחרת בהסכמה מפורשת של כלל בעלי הדירות או בתקנון מוסכם שנרשם כדן, קיר חיצוני, ובכלל זה הקיר הדרומי הנדון, נותר רכוש משותף.

68. וכן, איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה מכיוון שמשפחת לבני נזקקה להרשאה משועלי בכל הקשור לדוד השמש, יש להסיק כי משפחת לבני סברה שדוד השמש ממוקם בהצמדת דירת הנתבעים. לעיתים, דיירים מבקשים את הסכמת שכניהם לביצוע פעולות מסוימות, גם אם אינן מחייבות מבחינה משפטית, וזאת מתוך רצון לשמור על יחסי שכנות תקינים ולמנוע מחלוקות עתידיות. ייתכן כי הבקשה נבעה מזהירות גרידא, או מחוסר ודאות לגבי הגבולות המדויקים של הרכוש המשותף אל מול הרכוש הפרטי, ולא מתוך הכרה מפורשת בבעלות הנתבעים. כך או כך, אין בהתנהלות זו כדי להעיד על ויתור על זכויות או על הכרה בזכויות של אחר. מיקום דוד השמש ייבחן על פי הדין והראיות המהותיות, ולא על בסיס היסקים שאינם עומדים במבחן הביקורת המשפטית. כעולה מתשריט הבית המשותף, הקיר הדרומי ממוקם בחלק שהוא רכוש משותף. כך גם דוד השמש ממוקם בחלק שהוא רכוש משותף.

69. לכן, הנתבעים לא היו רשאים לבנות את הקיר הדרומי, בוודאי שלא מעבר לגובה של 1.30 מטר [ראו עדותו של מר ירון הלפגוט (בעמ' 17 ש' 3)] אף אדריכלית הנתבעים, הגב' מיכל ראבד העידה כי בניית הקיר: **"זה שינוי מהיתר הבניה שנעשה, ארצה להדגיש שלא יתווספו שטחים נוספים במסגרת השינוי ביחס להיתר הבניה המקורי, נעשה שינוי באופן הבינוי שאותו יש להסדיר בהיתר"** (עמ' 43 לפרוטוקול). הנתבעים לא היו רשאים לקרות מעל הדוד של משפחת לבני ולחסום אותו ולהזיזו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפיכך, על הנתבעים לסלק את הגג שיצקו בין הקיר הדרומי לחדר המעלית. במאמר מוסגר יצוין שאדריכלית הנתבעים, לא ביקרה בגג לצורך הכנת דעתה (ש' 21-26, עמ' 44 לפרוטוקול הדיון) ועניין זה פועל לחובת הנתבעים.

70. בנקודה זו מצאתי לנכון להרחיב על אופן הצבת דוד שמש בשטח הרכוש המשותף, וזאת גם בשים לב לכך שדוד השמש של הנתבעים הוצב על גג חדר המעלית שהוא רכוש משותף. סעיף 59א לחוק המקרקעין קובע כדלקמן: "(א) בעל דירה רשאי, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן – דוד שמש)..." בהמשך הסעיף קובע החוק כך: "(ב) בעל דירה בבית משותף שגגו אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית, לא יהיה רשאי להתקין דוד שמש כאמור בסעיף קטן (א) אלא לאחר שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם בעל דירה אחרת התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח להרשות את התקנת דוד השמש."

71. עולה כי לשם הצבת דוד שמש על גג שהוא שטח משותף אשר אין בו מקום למספר דודים כמספר הדירות בבניין, כמו במקרה שלפנינו, נדרשת הסכמה מלאה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. הסכמה זו וחזרה מהסכמה שכזו תלויים באיזון בין האינטרס של נהנה הזכות ושל הזכויות הקנייניות של בעלי הדירות [ביחס לאופי ההסכמה במקרקעין ראו הדברים שנקבעו על ידי כב' השופטת דפנה ברק ארז בעניין ע"א 483/16 יהודאי נ' חלמיש – חברה ממשלתית – עירונית לדיוור שיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב בע"מ (נבו, 3.10.2017)].

72. לכך יש להוסיף שהרוכש דירה בבית משותף, צריך לדעת שרכש נכס עם מגבלות ולא בחלל ריק. היטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין אשר קבע (רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו – 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994) (להלן – "עניין צודלר") כי: "הרוכש דירה בבית משותף – הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת – מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה". ובהמשך: "אכן, גילויה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילויה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

73. כפי שכבר כתבתי בעבר ביחס לקולטי דוד שמש [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 8/21 שרון שביט רביבו נ' שטיגל מיכאל (נב) 7.7.2022)], זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית, מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית ולכן, יכול וזכות זו תהיה כפופה, בנוסף להגבלות לפי דין או לפי הסכם, לזכויות שימוש של אחרים בבית. כך לדוגמה, בדירות רבות בבתים משותפים עוברות צנרת הביוב והניקוז המשותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות מסוג אלו בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" קבע "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". לאמור, בבית משותף ייתכן שרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו (ראו גם: (נתניה) 20-279 איציק אלמוג נ' אמנון שלומוף (נב) 27.12.2021).

74. מרקם החיים בבית המשותף, על מורכבותו וייחודו, מחייב הבנה כי אין מדובר באוסף של יחידות נפרדות לחלוטין, אלא ביחידה אורגנית אחת, שבה קיימת תלות הדדית מהותית בין כלל בעלי הדירות. תלות זו באה לידי ביטוי מובהק בקיומן של תשתיות חיוניות, אשר מונחות ועוברות בתוך דירות פרטיות, אך אינן משמשות בהכרח את בעל הדירה שבשטחו הן עוברות, אלא את כלל הדיירים או חלקם. דוגמאות לכך מצויות בשפע: כך הדבר בכל הקשור לתשתיות חשמל, ביוב, גז ומים, אשר צינורותיהן וכבליהן חוצים לעיתים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קרובות קירות ורצפות של דירות פרטיות, אך נועדו לשרת את הבניין כולו או מספר דירות בו. עקרון זה תקף באותה מידה גם בכל הקשור למתקנים הממוקמים על גגות, כגון אנטנות, צלחות לוויין ודודי שמש, לעיתים גם כאשר גגות אלו הוצמדו לדירה או לדירות ספציפיות בבית המשותף. הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת, אינה מנתקת אותו לחלוטין מהקשר הכללי של הבית המשותף. הצמדה זו עלולה להיות כפופה, מעצם טבעה ותכליתה, לזכויות שימוש ומעבר באותם מתקנים חיוניים. הרציונל לכך ברור: לא ניתן לאפשר מצב שבו הצמדה קניינית פורמלית תפגע באופן בלתי סביר ביכולת לספק שירותים חיוניים לכלל הדיירים, או למנוע תחזוקה ותיקון של תשתיות קריטיות. זכות הבעלות בדירה בבית משותף, ובכלל זה הזכות על שטח מוצמד, אינה מוחלטת, והיא ככלל, כפופה לאיזון אינטרסים עם צרכי הכלל ועם תפקודו התקין של הבית המשותף כיחידה אחת. [(המפקח על המקרקעין חיפה) 729/16 ח'ורי עפו נ' שאער מוניב, בפסקאות 38-40 (נבו 02.05.2019); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 493/19 חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית (נבו 02.09.2021)].

75. ובחזרה לענייננו - דוד השמש של משפחת לבני הוצב ברכוש המשותף על גג הבית המשותף (ראו גם עדותו של מר מימון, ש' 29-30 בעמ' 48 לפרוטוקול הדיון). אין מחלוקת כי דוד השמש הוצב לפני תקופה ארוכה, והרבה לפני שהנתבעים רכשו את דירתם ממשפחת שועלי, והוא הוצב שם בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, כולל משפחת שועלי, בעלי הדירה הקודמים של דירת הנתבעים (ראו עדותה של גב' שועלי, ש' 31-34 בעמ' 64 לפרוטוקול).

76. אולם מנגד, דוד השמש של הנתבעים, כמו ייתר המתקנים שהציבו על גג חדר המעלית, הוצבו רק לאחרונה, תוך תפיסת שטח מיכלי המים והאנטנות שהיו מוצבים במקום קודם לכן. החמור מכל הוא שהצבה זו נעשתה ללא קבלת הסכמתם של יתר בעלי הדירות (כפי שנקבע באסיפת בעלי הדירות מתאריך 1.1.2020 וכפי שיוסבר בהמשך). היעדר הסכמה זו אינו עניין טכני גרידא, אלא פוגע בליבת עקרון השיתוף בבית המשותף ובזכותם הקניינית של כלל הדיירים ליהנות מהרכוש המשותף. שימוש ייחודי ברכוש משותף, ובפרט כזה הכרוך בהסרת מתקנים קיימים והצבת חדשים, מחייב הסכמה של בעלי הדירות, או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוראה מפורשת בתקנון. בהיעדר הסכמה כזו, פעולת הנתבעים מהווה פלישה לרכוש המשותף, שימוש בלתי מורשה בו, ופגיעה בזכויות יתר בעלי הדירות. משכך על הנתבעים לסלק את ידם מתוך גג המעלית עם כל שאר התשתיות שהקימו על גביו.

77. לא נעלם מעיניי, ואף נתתי דעתי לטענת הנתבעים, אשר הועלתה הן במסגרת הליכי ההוכחות והן בסיכומיהם, ולפיה מיכלי המים, צלחת הלוויין וכולא הברקים שהיו מוצבים על שטח גג חדר המעלית לא היו בשימוש במשך חמש עשרה שנים קודם לתחילת הליך זה. אולם, וזהו העיקר, גם אם אקבל את טענתם העובדתית בדבר חוסר שימוש ממושך במתקנים אלו, אין בכך כדי לשנות, ולו כהוא זה, ביחס לצורך המהותי של הנתבעים בקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות על מנת לעשות שימוש ייחודי ובלעדי בגג המשותף. הרכוש המשותף, מעצם הגדרתו ומהותו המשפטית, שייך לכלל בעלי הדירות. זכות זו אינה מתבטלת או נגרעת מעצם העובדה שחלק מסוים מהרכוש המשותף אינו נמצא בשימוש פעיל על ידי מי מבעלי הדירות, או אף על ידי כלל בעלי הדירות, לתקופה מסוימת. היעדר שימוש אינו שקול לויתור על זכות קניינית. כל עוד השטח מסווג כרכוש משותף, הוא נותר כזה, וכל שימוש ייחודי בו מחייב הסכמה מפורשת. שאחרת, קבלת טענה כזו הייתה פותחת פתח מסוכן ל"השתלטות" על שטחים משותפים שאינם בשימוש מידי, ובכך הייתה פוגעת אנושות בעקרון השיתוף ובזכויות כלל בעלי הדירות. על כן, גם בהינתן טענתם בדבר חוסר שימוש, נטל ההוכחה בדבר קבלת הסכמה כדין לשימוש ייחודי נותר על כתפי הנתבעים, ונטל זה לא הורם.

78. הנתבעים הוסיפו וטענו כי אף אם ייקבע כי הבנייה בוצעה על שטחי הרכוש המשותף, סעד סילוק היד יהיה תוצאה לא ראויה אשר פוגעת באופן לא מידתי בנתבעים. כמו כן טענו הנתבעים כי התובעים עושים שימוש בחוסר תום לב בזכותם הקניינית בכך שהם מסרבים לכל בקשה מצד הנתבעים אך מאשרים כל בקשה של דייר אחר בבית המשותף. ביחס לכך אציין, כי ככלל, אין הבדל בין בניה על הרכוש המשותף לבין בניה על שטח המוצמד לדירה פלונית מבחינת ההסכמה הקניינית הנדרשת משאר בעלי הדירות לביצוע הבניה, ובהעדר הסכמת יתר בעלי הדירות, לא היו רשאים הנתבעים לבנות בשטחים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שבמחלוקת, אף אם אכן היו שטחים אלו מוצמדים לדירתם. הדברים קיבלו משנה תוקף בפסיקתו של בית המשפט העליון בע"א 7156/96 יעקב וברטה שואעי נ' דניאל בכרך, פסקה 2 לפסק הדין של השופט מצא נג(1) 469 (1999): "נקודת המוצא לדיון בשאלה הראשונה היא, שכלל יש להבחין בין הצמדת חלק מחלקת הרכוש המשותף לאחת מן הדירות בבית המשותף, לבין זכות בעל הדירה לבנות על השטח הצמוד. הצמדת שטח לדירתו מקנה לבעל הדירה זכות בעלות בשטח המוצמד. אך מכאן לא נובע, שלבעל הדירה כמה זכות לבנות על השטח המוצמד. זכויות הבנייה בבית משותף שייכות (מכוח בעלותם המשותפת בקרקע) לבעלי כל הדירות בבית, וניצולן על-ידי בעל דירה מותנה בהסכמת יתר בעלי הדירות." בית המשפט העליון חזר על קביעה זו גם בע"א 10322/03 לביא ישעיהו נ' אליעזר יעקב שטרייכר, נט(6) 449 (2005) וברע"א 11017/08 נתן פל נ' מרדכי ליבוביץ (נבו 16.8.2010).

79. בענייננו, הודה למעשה הנתבע כי ביצע פעולות שהשפיעו על הרכוש המשותף,

וכך גם קיבלו דבריו של הנתבע, מר מימון ביטוי בעדותו:

ש: אתה השתלטת עליו? על גג חדר המעלית

ת: אני הנחתי עליו דוד שמש, חפצים שלי.....

(עמ' 52 ש' 47-48)

ש: חסמת את דלת היציאה לגג?

ת: זה דלת שלי. צד אחד רכוש משותף וצד אחד הדירה שלי.

(עמ' 53 ש' 1-2).

ש: קיבלת אישור כדי לפצוע את הקיר המשותף?

ת: לא חשבתי שצריך לקבל אישור, זה צנרת

(עמ' 56 ש' 33-34)

80. אשר לטענות הנתבעים ביחס לשימוש בחוסר תום לב בזכות הקניין של

התובעים. אכן כטענת הנתבעים זכות הבעלות, ככל זכות, אינה בלתי מוגבלת.

ובין השאר עשויה להיות מוגבלת על-ידי חובת תום הלב החלה על בעל הזכות.

זאת בהתאם לפסק דין ע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פד"י נה(1) 199 (1999) (להלן-

"פסק דין רוקר") שאותו ציינו הנתבעים בסיכומיהם.

81. במסגרת פסק דין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול

הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. (ההדגשות כאן ובהמשך אינן במקור, מ"פ)

עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242)

82. בהתאם לעקרונות אלו, וביישום מדוקדק לענייננו, השתכנעתי כי אכן הפעולות שבוצעו על ידי הנתבעים בקומת הגג פוגעות באופן ממשי, עמוק ובלתי הפיך, באינטרסים הלגיטימיים והמוגנים של התובעים. אין מדובר בפגיעה זניחה או טכנית, אלא בפגיעה בזכות הבעלות במקרקעין מוסדרים, שהיא זכות קניינית מן המעלה הראשונה והיא מתבטאת במספר מישורים: ראשית, יש לזכור כי שטחי הגג המשותף בבית משותף זה מצומצמים באופן משמעותי מלכתחילה, בהשוואה לשטחי הגג שהוצמדו לדירת הנתבעים. במצב דברים זה, כל השתלטות נוספת של הנתבעים על שטחי הגג המשותף, ולו בשטח קטן יחסית, פוגעת באופן בלתי סביר ביכולתם של יתר בעלי הדירות, לעשות שימוש סביר והוגן בגג המשותף. זכות השימוש ברכוש המשותף היא זכות מהותית, וצמצומה, במיוחד כאשר מדובר בשטח מצומצם מלכתחילה, מהווה פגיעה קניינית ברורה. שנית, הפעולות שביצעו הנתבעים, ובכלל זה הגבהת הקיר הדרומי, משנות באופן דרמטי את צורתו החיצונית של הבניין. חזות הבניין, אופיו האדריכלי ושלמותו המבנית, הם אינטרסים לגיטימיים ומוגנים של כלל בעלי הדירות. אין לבעל דירה אחד זכות לשנות את חזות הבניין באופן חד-צדדי, ובכך לכפות על יתר הדיירים מראה שאינו לרוחם. אינטרס זה מהווה טעם מוצדק וברור של התובעים לסרב לבקשת הנתבעים, ולעמוד על זכותם לשמור על אופי הבניין. שלישית, ולכך יש להוסיף כי השטח שבמחלוקת, אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתפס על ידי הנתבעים, אינו שטח שניתן להחשיבו כקטן וזניח, במיוחד שעה שמדובר בתפיסה לצמיתות. אין זו תפיסה ארעית, ואין זה מעבר זמני או שימוש חולף, אלא השתלטות קבועה על חלק מהרכוש המשותף. עוצמת הפגיעה, במקרה זה, גבוהה במיוחד, שכן היא מונעת לצמיתות מיתר בעלי הדירות את האפשרות לעשות שימוש בחלק זה של הרכוש המשותף, ומשנה את אופיו באופן בלתי הפיך. לפיכך, בהינתן כלל הנסיבות, אין מנוס מלקבוע כי הפגיעה בזכויות התובעים היא מהותית, ובלתי מידתית, וכי טענותיהם של התובעים בעניין זה מוצדקות, ויש להורות על סילוק היד.

83. אשר לסעד שעניינו השמשת דוד השמש של משפחת לבני, ער אני לכך שלבקשת התובעים, הוחלף תצהירו של התובע לבני מהתיק בתצהירו של מר יעקובוביץ (ראו ההחלטה מיום 22.2.2023). אלא שאין בכך כדי לגרוע שהוא זה מהמחלוקת המהותית ומהממצאים העובדתיים שהוצגו בפניי. אין חולק, וזוהי קביעה עובדתית מוצקה, כי דוד השמש השייך למשפחת לבני הוזז ממקומו המקורי. יתרה מכך, הזזת הדוד הייתה תוצאה ישירה של פעולה שבוצעה על ידי הנתבעים, או מי מטעמם. עובדה זו אף זכתה לאישוש מפי הנתבעים עצמם: בעדותו, הודה מר מימון, הנתבע, כי "יכול להיות שהפועלים הזיזו, אני לא הזזתי, אני לא מסוגל להזיז" (עמ' 49, שורה 3 לפרוטוקול). הודאה זו, גם אם מנוסחת באופן עקיף, מהווה למעשה קבלת אחריות לכך שהזזת דוד השמש אכן התרחשה כתוצאה מפעולות הבנייה שביצעו הנתבעים. אין זה משנה אם הנתבע בעצמו הזיז את הדוד פיזית; די בכך שהפעולות שביצעו או הורו לבצע, הובילו להזזתו. לפיכך, הסעד המתבקש והראוי הוא השבת המצב לקדמותו ועל הנתבעים מוטלת החובה להשיב את דוד השמש (לרבות כל מתקניו הנלווים) של משפחת לבני למקומו המקורי, באופן תקין ופונקציונלי, וזאת על חשבונם.

על הנתבעים לאפשר לנציגות הבית המשותף לממש את זכותה להיכנס לרכוש המשותף ועל הנתבעים להשיב את המצב לקדמותו ביחס לדלת הפלדה שאטמו הנתבעים

84. כאמור, לטענת התובעים, דלת פלדה שהוצבה במשך שנים רבות, ושדרכה ניתן היה להגיע לרכוש המשותף, נאטמה על ידי הנתבעים, באופן שמונע מהתובעים גישה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ושימוש סביר ברכוש המשותף. להלן תמונת הדלת לפני אטימתה, כפי שהוצגה בראיות התובעים:



85. איני מקבל את טענת הנתבעים לפיה כלל הוא שלכל בעל דירה יש בעלות עד קו האמצע של המחיצה המפרידה בין דירתו לבין הרכוש המשותף, ולפיכך רשאים היו הנתבעים לאטום את דלת הפלדה שהייתה קבועה בקיר על הגג הפונה לדירת הנתבעים.

86. עיון במסמכי הרישום - בנסח הרישום, בצו הרישום, בתקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף ושלו מעמד קנייני [רע"א 3463/11 עזבון המנוח אהרונ שילמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ (נבו 16.01.2013)], מעלה כי ההצמדות שהוצמדו לדירת הנתבעים, תת חלקה 9, הן: חנייה המסומנת ה' בתשריט; גג המסומן י' בתשריט וגג נוסף המסומן י"א בתשריט. הקירות החיצוניים, לא הוצמדו לדירת הנתבעים, כך שהקיר החיצוני שבמחלוקת, הוא בהכרח רכוש משותף. כפי שהוסבר לעיל, וכפי שנקבע בפסק דין חיים לוי לעיל, קיר חיצוני הוא ככלל רכוש משותף גם אם הוא פונה לדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

87. בסיכומיהם הפנו הנתבעים לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בעניין 213/70 ת"א (מחוזי חיפה) 213/70 קפן הרברט נ' שמעוני יוסף, תשלד(2) 397 (1973) (להלן- "פסק דין קפן") וכן לפסק הדין שניתן על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) ציפי קווינט שילוני בעניין (המפקח על המקרקעין רחובות) 452/18 דרכלר ארתור נ' עו"ד איילת נבו (נבו 27.4.2020) (להלן- "פסק דין דרכלר"). אלא שכאמור, מעבר לכך שפסק דין חיים לוי, ניתן על ידי בית המשפט העליון, גם פסקי הדין שאליהם הפנו הנתבעים, אין בהם כדי לסייע להם. בפסק הדין בעניין דרכלר, הסבירה היטב כב' המפקחת (כתוארה אז) שילוני, את ההבחנה בין פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין חיים לוי, לבין פסק הדין המחוזי בעניין קפן, וקבעה כי "קירות מעקה המרפסת, בצד הפנימי... מהווים רכושן הפרטי של הנתבעות 1 ו-2 ולפיכך עליהן מוטלת האחריות לתיקונם. ואולם, שונה הדבר בכל הנוגע לליקויים שנתגלו בקירות 1, 2 ו-3. צד זה של הקיר בו מצויים הליקויים, הגם שפונה הוא אל המרפסות, הוא מהווה רכוש משותף לכל דבר ועניין. על כך עמד בית המשפט העליון הנכבד בע"א 381/66 חיים לוי ו-9 אח' נ' מרים לנקביץ' (פורסם בנבו, 20.11.66)...". אבחנה זו, יפה גם לענייננו. הקיר החיצוני נותר חלק אינטגרלי ממעטפת הבניין כולו, המשרת את כלל הדיירים. דלת הפלדה, הייתה ממוקמת בחלק שאין מחלוקת שהוא רכוש משותף, ומשכך, אסור היה לנתבעים לחסום אותה.

התביעה שכנגד

אין סמכות עניינית לדון בתיקון צו רישום בית משותף

88. הנתבעים ביקשו שיינתן סעד במסגרתו יתוקן צו רישום הבית המשותף, באופן שישקף את שטח דירת הנתבעים בפועל, ככך ששטח דירתם הרשום יהיה 197 מ"ר, ובאופן שהחלק של הנתבעים ברכוש המשותף יעמוד על 19.2%.

89. אלא שאיני יכול להעניק לנתבעים את הסעד המבוקש, ואסביר. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים מוסדרת בסעיף 72 לחוק המקרקעין. בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו [ראו: ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(1) 730 (1974); ע"א 664/71 **עורקבי נ' נקר** פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 **שליט נ' גולדברג** פ"ד כ"ד (1) 231].

90. סמכויותיו של המפקח בכל הקשור לרישום בתים משותפים ותיקונם (לרבות תיקון צו בית משותף) הן **סמכויות מנהליות** המוסדרות בסעיפים אחרים המנויים בסימן ד' לפרק ט' לחוק המקרקעין. כך למשל, הסמכות ליתן צו לרישום בית משותף (סעיף 143 לחוק), תיקון צו בית משותף (סעיף 145 לחוק) וביטולו (סעיף 146 לחוק). סמכויות אלה אינן חלק מסמכויותו השיפוטיות ועל כן אף דרך הערעור עליהן שונה. בעוד שעל החלטה שיפוטית שהתקבלה בהתאם לסמכויותיו של המפקח על-פי סעיף 72 לחוק, הערעור הוא לבית המשפט המחוזי (סעיף 77 לחוק), ערר על החלטה מנהלית של המפקח מופנה לממונה על המרשם (סעיף 121 לחוק). [על ההבחנה בין סמכויותיו השיפוטיות לבין סמכויותיו המנהליות של המפקח, ראו בהרחבה גם ע"א 34256-02-13 **זלינגר נ' הממונה על המרשם** (נבו 16.06.13); ע"א (מחוזי ירושלים) 58158-05-19 **מוהדב נ' רישרד ואח'** (נבו 3.10.2019); ע"א 44/72 **צפורה ו-דוד שם טוב נ' פנינה פריבר**, כו(1) 617 (1972); כן ראו בשינויים המתאימים את פסק הדין בעניין ת"א (מחוזי תל אביב-יפו) 53430-03-23 **רויאלטי זק שוויצריה הקטנה בע"מ נ' פ.ט.כ. יבוא ושיווק מוצרי אלקטרוניקה בע"מ**, בפסקה 21 (נבו 12.5.2025)].

91. העובדה כי מדובר בסכסוך בבית משותף אין בה, כשלעצמה, להקנות למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בסעד המבוקש שעניינו כאמור תיקון צו הבית המשותף בהתאם לסעיף 145 לחוק המקרקעין. לפיכך, איני יכול להידרש לסעד המבוקש. יובהר כי אין בכך כדי לחסום את הנתבעים לפעול לתיקון צו רישום הבית המשותף, בפני הגורמים המתאימים לכך, תוך ששמורות לצדדים מלוא טענותיהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השינויים שבוצעו ברכוש המשותף בעניין סוכך החניה של משפחת לבני, קיבלו את אישור האסיפה הכללית, ומשכך נדחים הסעדים המבוקשים בגינם

92. לבית המשותף נרשם אומנם תקנון מוסכם, אך הוא שותק ביחס לאפשרות לבצע שינויים ברכוש המשותף, ולכן יחולו על הבית המשותף הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין (להלן - "התקנון המצוי").

93. סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין קובע כי: "**בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה**".

94. פגיעה ברכוש המשותף מפורשת בפסיקה באופן רחב והיא כוללת כל פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית או שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא [ראו למשל ע"א 395/74 לוי נ' סמואל פ"ד כט (2) 39 (1975); ע"א 429/80 גרפינקל נ' ארליך, פ"ד לז (4) 148-147 (1983)].

95. וכן, אישורה בדיעבד של האסיפה הכללית יכול לרפא את הפגם שבאי קבלת הסכמתה של האסיפה הכללית מראש, כנדרש בסעיף 2(א) לתקנון המצוי [ראו למשל ע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, מ(1) 724 (1986); ע"א (מחוזי ת"א) 6262-11-18 ערן בן חורין נ' נציגות הבית המשותף רחוב קדושי 56 הרצליה ואח', בפסקה 12 (נבו 27.10.2019); (המפקח על המקרקעין חיפה) 222/23 פוקס טל נ' פרייברט דוד-דמיטרי, בפסקה 58 (נבו 12.02.2024)].

96. ובמיושם לענייננו - כעולה ממוצג ט"ו לתיק מוצגי התובעים, בתאריך 1.1.2020, התקיימה אסיפת בעלי דירות, שבה נכחו 9 בעלי דירות, וביניהם גם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבע 1, מר מימון. (להלן - "פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות") במסגרת האסיפה, התקבלו כמה החלטות ברוב של שמונה בעלי דירות, ובהתנגדות הנתבע 1. בין השאר התקבלה החלטה המאפשרת שימוש במסדרונות הקומתיים לצורך הצבת ריהוט, אישור המשך החזקת הצבת סככה מעל חניית משפחת לבני, פתיחת פתח לרכוש המשותף ועוד.

97. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובראיות שצורפו להליך, ושמעתי באריכות את העדים ואף ביקרתי במקום וראיתי באופן בלתי אמצעי את סוכך החניה. לא השתכנעתי כי קיים טעם המצדיק את הריסת הסוכך ושיש בהצבתו פגיעה בזכותם הקניינית של הנתבעים. אוסיף עוד שמסקנה זו מתחזקת נוכח ההסכמות שקיבלו התובעים לבני משאר הדיירים בבניין ונוכח הזמן הרב שחלף מאז הוצבה הסככה ועד שהוגשה התביעה על ידי הנתבעים.

98. אשר ללולאת טבעת הברזל לקשירת האופנוע של מר הברמן. עברתי בעיון על פרוטוקול אסיפת בעלי הדירות ולא מצאתי בו כל התייחסות ביחס ללולאת האופנוע של מר הברמן. בעדותו, הודה מר הברמן שלא קיבל אישור להצבת הלולאה ברכוש המשותף (עמ' 26 ש' 44-45 לפרוטוקול הדיון). לפיכך, יהיה על מר הוברמן לסלק את לולאת טבעת הברזל שהותקנה ברכוש המשותף, אלא אם יקבל את אישור אסיפת בעלי הדירות, ברוב הדרוש, וזאת בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין.

טענת הנתבעים בדבר שינויים שבוצעו בניגוד להיתר בנייה, לרבות הקטנת חלונות ופתחים, וונטות לאוורור - כל אלו עניינים בפן התכנוני

99. כאמור, הצדדים הרבו לטעון ביחס לנושאים התכנוניים וההיתרים שניתנו לבית המשותף במהלך השנים. הנתבעים טענו כי בדירות חלק מהתובעים בוצעו שינויים בניגוד להיתר ולפיכך יש להורות על הריסתם. לטענת הנתבעים, שינויים אלו כללו סגירת מרפסות ושינוי מראה הבניין על ידי הקטנת חלק מהחלונות והוספת וונטות לאוורור על גבי הרכוש המשותף והכל בניגוד להיתר הבנייה. טענות אלו של הנתבעים, נתמכו בחוות דעתה של אדריכלית הנתבעים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

גב' מיכל ראבד שהעידה מטעמים והצביעה על השינויים השונים שבוצעו, אל מול ההיתרים התכנוניים.

100. מר יעקובוביץ העיד כי מעולם לא סגר מי מהדיירים מרפסות בבניין, וכי צורתו של הבניין תואמת המצב כפי שהוא היה בעת שנמסר מהקבלן לדיירים (עמ' 34 לפרוטוקול הדיון). כך גם העיד מר הברמן : **"מכיוון שכמו שאמרתי אני דייר בבניין מיום אכלוסו, שנת '79, אני יכול להעיד פה בביטחון מוחלט שככה כל הבניין נראה בסיום בנייתו"** (עמ' 20 ש' 20-21 לפרוטוקול; כן ראו עדותו של מר הברמן ביחס לוונטות בעמ' 28 ש' 42-46 לפרוטוקול).

101. נציג העירייה מר ירון הלפגוט, אישר בעדותו כי כל שינוי בחזית הבניין לרבות צבע הבניין דורש היתר מטעם העירייה. בין השאר העיד מר הלפגוט כי: **"כל שינוי בצורה בנראות של המבנה ב360 מעלות שלו למעלה ולמטה, פתיחת פתח בשטחים משותפים, שינוי קונסטרוקטיבי וכל שינוי שנוגע לשכנים כמו שהגדרה בחוק כתובה, זה משהו שטעון היתר"**. (עמ' 17 ש' 17-21 לפרוטוקול). כן העיד מר הלפגוט, כי קיים תיק חקירה פתוח ופעיל, ביחס לבית המשותף (עמ' 17 ש' 36-39 לפרוטוקול).

102. אלא, כפי שכתבתי בהרחבה לעיל, המפקח על רישום מקרקעין אמון על הפן הקנייני, ואינו דן בפן התכנוני. לפיכך טענות הנוגעות להיתרי בניה אמורות להתברר על ידי מוסדות התכנון ולא על ידי המפקח. נדמה כי כלל זה ידוע היטב לצדדים, לרבות לנתבעים, אשר אף הדגישו בסיכומיהם כי "המפקח אינו נדרש להליכים התכנוניים אלא להליכים קנייניים, וכי הוא אינו יושב כערכאת ערעור על החלטות תכנוניות... (סעיף 3 לסיכומי הנתבעים). כך שטענות הנתבעים ביחס לשינויים שבוצעו לטענתם בניגוד להיתר, שמורות להן בפני הערכאה המתאימה, ובכפוף לכל דין. מסיבה זו גם לא מצאתי טעם להידרש לטענות הצדדים, ביחס לנושא ההתיישנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

**סעד דמי שימוש בגין דוד השמש של משפחת לבני, נדחה מהטעם שדוד השמש
הוצב ברכוש המשותף, וממילא לא הוכח גובה דמי השימוש, ואין מקום לפסוק
דמי שימוש לפי אומדנה**

103. כפי שכתבתי בעבר (ראו למשל המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 634/19
חבאני גדעון נ' קומימי בנימין, בפסקאות 60-63, (נבו 13.12.2021), זכאות
לדמי השימוש, מתגבשת מכוח סעיף 1(א) לחוק עשיית עושר ולא במשפט,
תשל"ט-1979 הקובע כי "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או
טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה), חייב
להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה -
לשלם לו את שוויה" [ע"א 588/87 אליעזר כהן ואח' נ' צבי שמש, פד מה(5)
297 (1991); ע"א 889/75 "דריס" בע"מ נ' "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה
בישראל בע"מ, לא(2) 020 (1973)]. סעיף 33 לחוק המקרקעין שכותרתו
"תשלום בעד שימוש", קובע כי "שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב
ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש". דמי
שימוש ראויים, משקפים את נזקיו של בעל הקרקע מחד גיסא, ואת עשיית
העושר של הזוכה מאידך גיסא [ע"א 891/95 זידאני נ' אבו אחמד, פ"ד נג(4) 769
775-776 (1999)].

104. אלא שבענייננו כאמור, וכפי שקבעתי לעיל, דוד השמש של משפחת לבני, הוצב
בשטח שהוא רכוש משותף, ולא בשטח דירתם של הנתבעים ומשכך אין מקום
להורות על דמי שימוש ראויים.

105. אלא שגם אם הייתי קובע כי דוד השמש של משפחת לבני, הוצב בשטח דירתם
של הנתבעים, ולא כך קבעתי כאמור, לא היה מקום לפסוק לנתבעים דמי
שימוש ראויים, ואסביר. כפי שכבר כתבתי בעבר [ראו למשל (המפקח על המקרקעין
פתח תקוה) 712/22 עו"ד וכמן זאב נ' אסרף רפאל (נבו 28.5.2024)], על התובע להוכיח
לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק
[ע"א 9145/18 שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס
בע"מ, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021); רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בונייד בנייה פתוח
והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

106. איני מסכים עם טענת הנתבעים בסיכומיהם ביחס לפסיקת דמי שימוש על דרך של אומדנה. בהתאם לפסיקה כאמור, פסיקה על דרך האומדנה מהווה חריג והיא תיושם אך ורק במצבים חריגים ויוצאי דופן, שבהם הוכח קיומו של נזק (או התעשרות שלא כדין), אך אופיו וטבעו של הנזק יוצרים קושי מובנה, אובייקטיבי ובלתי ניתן להתגברות, להוכיח את שיעורו המדויק. בפסיקה הודגש כי ככלל, יש להימנע מפסיקה על דרך של אומדנה [ראו למשל דעת הרוב בע"א 355/80 **אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע**, פ"ד לה (2) 800 (1981); דנ"א 4693/05 **בי"ח כרמל-חיפה נ' מלול**, פסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (נבו) 29.8.2010].

107. הנתבעים טענו שדמי השימוש מוערכים בסך של 500 ₪ לחודש, בדרך של אומדנה החל מחודש מאי 2019 ועד לפינויו בחודש אוגוסט 2021 ובסך הכל 13,500 ₪. אלא, שהיה על הנתבעים להוכיח את גובה דמי השימוש, באמצעות ראיות מתאימות, כגון חוות דעת של שמאי, ולא על דרך של הערכה, ומשלא עשו כן, לא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח את גובה דמי השימוש, ולכן אני דוחה את רכיב התביעה ביחס לדמי השימוש הראויים, אף לגופו.

הנתבעים לא הוכיחו עמידה בתנאים שנקבעו לעניין השבת כספים ביחס לפעולות שבוצעו ברכוש המשותף

108. זכותו של בעל דירה לדרוש מנציגות הבית שתתקן ליקוי ברכוש המשותף הפוגע בדירתו, קבועה בסעיף 3(א) לתקנון המצוי: **בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה** (ההדגשה אינה במקור מ"פ).

109. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על נציגות הבית המשותף, לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף שאי ביצועו עלול לפגוע בערכה של דירה או ברכוש המשותף. חובה זו היא מוחלטת ובלתי תלויה בתשובה לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיה של נציגות הבית המשותף או ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז-1997) עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק."

110. בפסק הדין בעניין רע"א 4984/17 **שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא** (נבו 14.12.17) (להלן - "**פסק דין חיים**"), נקבעו שישה תנאים מצטברים כתנאי לזכאותו של בעל דירה בהחזר הוצאות אשר הוציא לשם תיקון ליקוי ברכוש המשותף: 1. הליקוי שתוקן הוא ברכוש משותף; 2. הדייר פנה לנציגות בדרישה לתיקון וזו סירבה לתקנו; 3. העיכוב שהיה נגרם בגין פנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי; 4. הוכחה נחיצות התיקון באופן שאי התיקון בהקדם יפגע בצורה קשה וברורה ביכולתו של הדייר להשתמש בדירתו; 5. הליקוי תוקן על ידי הדייר בצורה נאותה; 6. הוכחה עלות התיקון [ראו גם ההפניות לפסיקת בתי המשפט המחוזיים בהם אומצו במהלך השנים תנאים דומים: ע"א (י-ם) 179/84 **רוס נ' חפציבה חברה לבניין ועבודות פיתוח בע"מ** (נבו 3.6.1985) (להלן - "**עניין רוס**"); ע"א (מחוזי י - ס) 6403/05 **ביטון נ' דיירי הבית המשותף** (נבו 15.2.2006; עש"א (מחוזי חי') 5863-12-16 **אביטון נ' נציגות הבית המשותף** (נבו, 4.4.2017)].

111. תנאים מצטברים אלו, הם חד צדדיים, במובן זה שהם לא חלים כאשר נציגות הבית המשותף תובעת בעל דירה אחר בהחזר הוצאות שהוציאה ברכוש המשותף, אלא רק כאשר בעל דירה, דורש החזר כספי בשל ליקויים שלטענתו תיקן, ברכוש המשותף. בפסק דין **חיים** נפסק כי בעל דירה המבקש לתקן ליקוי ברכוש המשותף, צריך לפנות תחילה לנציגות בדרישה לפעול לתיקון הליקוי. ככל שפנייתו זו לא נענתה, הרי שדרך המלך היא להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, וזאת קודם לביצוע התיקון על ידו: **הטיפול במקרים בהם אחד הדיירים בבית משותף הוציא מכיסו הוצאות לצורך תיקון ליקויים ברכוש משותף, מחייב התייחסות למסגרת של דיני בתים משותפים. על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך** [ראו גם: עניין רוס, בעמ' 418].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

112. ובמיושם לענייננו - לטענת הנתבעים הם נאלצו להוציא מכיסם סכום של 19,188 ₪, עבור איטום ליקויי בגג חדר המעלית ופינוי מיכלי מים וצנרת. נטען שחרף התראות ודרישות, נמנעה הנציגות לפעול במשך חודשים, מה שאילץ את הנתבעים לבצע את תיקון הליקויים בעצמם.

113. עיון בתיק המוצגים של הנתבעים (נספחים 14-15) מעלה כי בתאריך 21.4.2020, פנה הנתבע 1 אל מר יעקובוביץ וביקש ממנו לפעול בעניין איטום גג חדר המעלית ולפינוי מיכלי האסבסט ההרוסים. בתאריך 22.4.2020, השיב לו מר יעקובוביץ כי ועד הבית לוקח על עצמו את הטיפול באיטום גג המעלית ויבצע זאת בהקדם. כמו כן ידאג לפינוי וניקוי הגג מהמכלים והצנרת, ומועד ביצוע העבודה יתואם עם הנתבעים בהמשך.

114. בתאריך 22.5.2020, שלחו הנתבעים דוא"ל נוסף לנציג התובעת מר יעקובוביץ (עמ' 77 לתיק מוצגי הנתבעים), ולפיו למרות שהייתה התחייבות לטפל במיכלי האסבסט ואיטום גג חדר המעלית לפני למעלה מחודש, לא בוצע הדבר, ולפיכך ככל שהנושא "לא יטופל עד 1.6.20 אאלץ לעשות זאת בעצמי".

115. לנספח 15 לתיק מוצגי הנתבעים, צורפו שלוש חשבוניות. מהן עולה כי בתאריך 29.6.2020, שילמו הנתבעים סך של 5,000 ₪ עבור פינוי מיכלי אסבסט, וכן חשבונית מס קבלה שהוצאה על ידי חב' חלבי אמל ובניו איטום בע"מ בתאריך 3.8.2020, ממנה עולה כי בתאריך 1.6.2020, שולם במזומן סך של 6,318 ₪ עבור בנית קיר בלוקים וכן חשבונית מס קבלה שהוצאה גם היא ע"י חב' חלבי אמל ובניו איטום בע"מ בתאריך 3.8.2020, ממנה עולה כי בתאריך 1.7.2020, שולם במזומן סך של 7,020 ₪ עבור איטום קיר חומה צד פנימי גג מעלית.

116. אלא שכאמור, לצורך עמידה בתנאי ההחזר, יש לעמוד בשישה תנאים מצטברים. אך בענייננו, הנתבעים לא עמדו בהם. כך למשל, הנתבעים לא עמדו בתנאי המהותי שלפיו קדמה פנייה לנציגות הבית המשותף או ליתר הדיירים בדרישה לתיקון הליקוי, וכי פנייה זו סורבה. תנאי זה אינו טכני גרידא, אלא נועד לאפשר לגוף המוסמך, קרי, הנציגות, לטפל בעניין, לבחון את הליקוי, להחליט על דרך הפעולה המתאימה, ולגייס את המשאבים הנדרשים מכלל בעלי הדירות. בענייננו, מהמסמכים שהוצגו עולה בבירור כי בתאריך 22.4.2020,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התחייבה הנציגות לפעול בעניין. התחייבות זו משמעותה שהנציגות נטלה על עצמה את האחריות לטפל בנושא, והיה על הנתבעים להמתין לפעולתה. אולם, הנתבעים לא המתינו פרק זמן סביר, וכבר בתאריך 1.6.2020, פרק זמן קצר ביותר לאחר התחייבות הנציגות, החלו בביצוע פעולות מטעמם ברכוש המשותף. פעולה זו, של נקיטת יוזמה חד-צדדית ללא מתן שהות מספקת לנציגות לממש את התחייבותה, מהווה הפרה ברורה של התנאי השני.

117. כך גם בכל הקשור לתנאי השלישי, שעניינו בחינת השאלה האם העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי. על חשיבותו של התנאי בדבר חשש להחמרת המצב בשל הפנייה למפקח, נאמרו הדברים הבאים, בפסק הדין חיים: **"במיוחד יש להדגיש את העובדה שלא הוכחה דחיפות לתיקון הליקוי, באופן שפניה למפקח לצורך הכרעה בסכסוך הייתה מביאה להחמרת הנזק באופן משמעותי. תנאי זה הינו חיוני והכרחי על מנת שדייר יזכה לשיפוי בגין הוצאות שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש משותף, שכן המסלול הרגיל מחייב פניה למפקח במקרה של סירוב הנציגות לתקן".** הרציונל העמוק מאחורי דרישה זו הוא כפול: ראשית, הוא נועד לשמור על הסדר הטוב בבית המשותף ולמנוע פעולות חד-צדדיות של "עשיית דין עצמית" על ידי מי מבעלי הדירות. שנית, הוא מבטיח כי המחלוקות יוכרעו על ידי הגורם השיפוטי המוסמך, אשר לו הסמכות והכלים לבחון את המצב, לשמוע את הצדדים ולקבל החלטה מושכלת. רק במקרים של דחיפות קיצונית, בהם כל עיכוב עלול לגרום לנזק בלתי הפיך או להחמרה משמעותית של המצב, ניתן לסטות מתנאי זה.

118. אלא שהנתבעים לא הוכיחו כי העיכוב בשל הפנייה למפקח היה מביא להחמרת הנזק באופן משמעותי ולא סיפקו כל הסבר, מדוע לא פנו למפקח. למעשה, עבודות האיטום בוצעו בחודשי הקיץ, חודשים שממילא לא יורדים בהם גשמים במדינתנו, ומשכך לא הייתה כל דחיפות בביצוע עבודות האיטום בחודשים אלו.

119. אלא שגם אין עמידה בתנאי הרביעי. הנתבעים לא הוכיחו שאי התיקון בהקדם היה פוגע בצורה קשה וברורה ביכולתם להשתמש בדירתם. בסיכומיהם לא טענו הנתבעים טענה ביחס לחוסר יכולת לעשות שימוש בדירתם בשל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הליקויים, ומשכך אין עמידה גם בתנאי זה. משלא עמדו הנתבעים במלוא התנאים המצטברים, לא זכאים הנתבעים להחזר, ותביעתם ביחס לכך, נדחתה.

לסיכום אופרטיבי

אשר לתביעה הראשית:

א. הגגות החדשים שנוצרו על ידי סגירת המרפסות בקומה החמישית מהווים חלק מהרכוש המשותף, ומשכך ניתן לעשות בהם שימוש סביר.

ב. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב את המצב לקדמותו ברכוש המשותף, וזאת בתוך 90 ימים מהיום ועל חשבונם המלא. השבה זו תכלול, בין היתר: הריסת תוספת הבנייה בקיר הדרומי; הריסת הגג החדש שיצקו בין הקיר הדרומי לחדר המעלית; פירוק כל המתקנים שהותקנו על גג חדר המעלית; והשבת כולא הברקים למצבו המקורי.

ג. בתוך 90 ימים מהיום, על הנתבעים, יחד ולחוד, להשמיש על חשבונם את דוד השמש השייך לדירת משפחת לבני, באופן שיבטיח את פעולתו התקינה.

ד. אני מורה לנתבעים, יחד ולחוד, להסיר בתוך 90 ימים מהיום ועל חשבונם, את החסימה המונעת את פתיחת דלת היציאה מחדר המעלית לגג. כמו כן, עליהם להשיב את חדר המעלית למצבו הקודם, לרבות פתיחת חלונות האוורור כפי שהיו.

אשר לתביעה שכנגד

א. בתוך 90 ימים מהיום, יסלק התובע 10 את לולאת טבעת הברזל שהותקנה ברכוש המשותף, אלא אם ידאג לכנס את אסיפת בעלי הדירות, ויקבל את אישור אסיפת בעלי הדירות, ברוב הדרוש, להשארת לולאת טבעת הברזל וזאת בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין.

הוצאות ההליך

120. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד [ע"א 9648/16 אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018)]. כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/198/2020, 6/451/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות).

121. כאמור, תקנה 153 (ג) לתקנות, קובעת שיש להביא בחשבון את התנהלות הצדדים ואת הדרך שבה ניהלו את ההליך. לפיכך, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו לעיל ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לסעדים שנתבעו במקור על ידי הצדדים, ולסעדים שנתבעו בפועל ולתוצאתם, החלטתי שעל הנתבעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות התובעים לרבות בשכ"ט עו"ד, בסך כולל של 12,500 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישא ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, י"ז שבט תשפ"ו, 04 פברואר 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין